

1501622-55.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPÇÃO EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA PARA O CRIME DE TRÁFICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE EXACERBADA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVADAS COM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501622-55.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501622-55.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2163674/2021 - DISE-DEL.SEC.GUARULHOS, 18545564 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 101/21/222 - DISE-DEL.SEC.GUARULHOS, 2163674 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE CARLOS SANTOS SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

FÁBIO GUIMARÃES DE LIMA e JOSE CARLOS SANTOS SILVA, qualificados nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, combinado com o artigo 61, II, j, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 16 de junho de 2021, por volta das 15h15min, na Rua Baianópolis, nº 100, interior da comunidade Jardim Ansalca, nesta cidade e comarca de Guarulhos (SP), agindo em concurso caracterizado pela unidade de desígnios, traziam consigo e guardavam, sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar, e para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 60,92g de cocaína, distribuídos em porções, 46,14g de crack, distribuídos em porções, 372,68g de maconha, distribuídos em porções, bem como 40ml de substância líquida similar a

lança-perfume, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13 e laudos de constatação e definitivo de fls. 15/20 e 77/79 (fls. 84/87).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/81).

Em 17 de junho de 2021, na audiência de custódia do Foro Plantão - 44ª CJ - Guarulhos, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva do acusado Fábio Guimarães de Lima, bem como foi concedido o benefício da Liberdade Provisória cumulado com as medidas cautelares ao acusado José Carlos Santos Silva (fls. 57/61).

Devidamente notificados (réu Fabio - fls. 113/114 e réu José Carlos - fls. 151/152), os acusados ofereceram defesa preliminar, com rol de testemunhas comuns (réu Fabio - fls. 125/127 e réu José Carlos - fls. 183/184).

A denúncia do acusado Fábio foi recebida em 17 de dezembro de 2021 (fls. 146/150).

Quanto ao acusado José Carlos, a denúncia foi recebida no dia 23 de fevereiro de 2022 (fls. 202/204).

Nesta data, na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas comuns. Em seguida, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), auto de prisão em flagrante delito (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão (fl. 13), laudo de constatação provisória de entorpecentes (fls. 15/20), exame químico-toxicológico (fls. 77/79, fls. 107/109 e fls. 110/112), dando conta de que as substâncias apreendidas tratavam-se de COCAÍNA, TETRAHIDROCANNABIDOL-THC, TRICLOROETILENO e CLORETO DE METILENO/DICLOROMETANO, laudo pericial de descrição de objeto (fls. 115/117), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria também é segura e aponta para os dois acusados, senão vejamos.

O acusado FÁBIO GUIMARÃES DE LIMA, em solo policial, respondeu que na data dos fatos, estava na companhia de Jose Carlos. Que ele chamou pra ajudá-lo na venda de drogas sendo que pagaria ao depoente R\$ 50,00 (cinquenta reais) para ficar como "Campana". Chegaram policiais disfarçados e não percebeu, indicou a eles o local onde comprariam drogas e foi abordado por um deles. Tinha um outro rapaz com o depoente, que conheço pelo nome de Douglas, mas não sabe mais a respeito dele. Na hora da abordagem foi impedido de fugir. Perguntado ao indiciado, se ele revistou os policiais civis, nada respondeu (fl. 07). Em juízo, negou veementemente os fatos. Disse que estava no ferro velho falando com a don quando foi abordado. Queria saber o que teria para receber em razão da reciclagem que tinha levado no final de semana. Não resistiu porque não devia nada. Confirmou que havia um ponto de venda de drogas próximo do local onde estava. Disse que os olheiros fugiram. Negou ter confessado na delegacia, mas chegou a ser coagido para tanto, eis que os policiais disseram que se não assumisse que era olheiro, dividiriam as drogas apreendidas entre ele e José. Estava trabalhando na época dos fatos. Disse que a Vania não quis ser sua testemunha por medo de retaliação e que seu empregador não quis dar comprovante para juntar ao processo. Não soube explicar porque consta uma confissão em seu interrogatório extrajudicial, nem porque o corré também teria admitido que ele estaria trabalhando como olheiro quando ouvido na delegacia, negou conhecer os policiais.

O acusado JOSE CARLOS SANTOS SILVA, em solo policial, respondeu que na data dos fatos estava na companhia de Fabio Guimaraes de Lima, que estava lhe ajudando no ponto de drogas, trabalhando como "Campana", Fabio recepcionava os compradores e indicava pra o depoente. Informa que estava na "sacola" vendendo drogas, sendo naquela data dos fatos, era o segundo dia que estava lá naquela biqueira. Chegou a

ganhar cerca de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia. Se aproximou um policial disfarçado e na hora que foi servir a droga para ele, se apresentou como policial civil e lhe prendeu. Um outro policial que estava mais atrás com o Fabio, o abordou e o prendeu também. Na hora da prisão se assustou e tentou correr, mas foi impedido e algemado (fl. 08). Em juízo, novamente confessou os fatos. Disse que estava com dificuldades financeiras e acabou aceitando traficar. Era seu segundo dia. Ganhava R\$ 150,00 por dia. Confirmou que tinha olheiros, mas negou saber os nomes deles. Negou que Fabio fosse um dos olheiros. Negou ter admitido na fase extrajudicial que Fabio fosse seu olheiro.

Os policiais civis GUSTAVO MINIACI LOPES, MANOEL PEDRO DA SILVA e RICARDO LACORTE, em sede inquisitorial, em depoimentos semelhantes, narraram que estavam em diligências no sentido de coibir o tráfico de drogas nesta Urbe. Em viatura descaracterizada, estacionaram de maneira velada pelo local dos fatos onde há uma viela que dá acesso a uma comunidade local. Avistaram indivíduos em fundada suspeita provavelmente comercializando entorpecentes naquele local. Gustavo e Lacorte decidiram pela abordagem, e se aproximaram passando por usuários. Foram recepcionados por dois indivíduos, que perguntaram o que queriam comprar. Solicitaram uma porção de droga e foram revistados e instruídos seguir adiante um de cada vez. Sendo que Lacorte seguiu na frente sentido ao traficante e Gustavo ficou aguardando com os supostos "olheiros". Durante a venda, o investigador Lacorte apresentou-se como policial e deu voz de prisão ao indiciado Jose Carlos, que trazia consigo uma sacola plástica contendo diversas substâncias entorpecentes já individualizadas, e uma quantia em dinheiro somando R\$ 35,00 (Trinta e cinco reais). Concomitantemente Gustavo deu voz de prisão ao indiciado Fabio Guimarães, que na tentativa de revistá-lo, ordenou que esperasse o retorno do outro. Nada de ilícito o indiciado Fabio tinha em posse, já que este indicou o local da venda de drogas e supostamente atuava como "Campana". Um terceiro indivíduo conseguiu evadir-se em desabalada carreira em meio a comunidade, tomando rumo ignorado, não sendo possível identificá-lo. O policial Manoel que aguardava próximo a viatura percebeu a ação e aproximou-se para dar apoio, já que no momento da prisão ambos ofereceram resistência e a todo momento tentavam desvencilhar-se na tentativa de fuga. Sendo assim, usaram de força moderada para conter a tentativa de fuga dos indiciados. Identificados como JOSE CARLOS SANTOS SILVA e FABIO GUIMARAES DE LIMA, assumiram informalmente estar atuando em conjunto na venda de drogas naquele local e nada mais disseram. Com o indiciado Thiago, nada de ilícito foi encontrado, visto que este atuava como "campana". Sendo assim conduziram os indiciados, drogas e demais objetos apreendidos e a delegacia para as providências de polícia judiciária (fls. 03/04, fl. 05 e fl. 06).

Em juízo, o policial civil GUSTAVO MINIACI LOPES se recordou dos réus de uma ocorrência de tráfico. Disse que ele e Ricardo foram ao local com uma viatura descaracterizada. Entraram os dois e Manoel ficou perto da viatura. Tinham dois seguranças na entrada que dava acesso a um matagal, onde tinha a movimentação de tráfico. Os seguranças revistavam as pessoas que entravam no local, para dar segurança para quem estava vendendo a droga. Se eles percebessem algo diferente dariam sinal e todos correriam. Disse que os indivíduos que estavam na função de segurança revistaram Ricardo, pedindo para levantar a camisa e depois autorizaram ele ir até o rapaz que estava vendendo o entorpecente. Quando seu colega estava comprando a droga com José, trocaram olhares e se apresentaram como policiais. Conseguiu segurar Fábio, um dos rapazes que fazia a segurança do local, enquanto o outro rapaz fugiu. Seu colega abordou o corréu Jose. Disse que com José foi apreendida uma sacola com bastante droga. Entende que os dois estão traficando, mas Fabio é quem exercia a função de segurança. Com Fábio não foi encontrada nada. Eles confessaram informalmente. Na hora que foram algemados não mostram mais resistência. Os réus não apontaram quem era o terceiro rapaz que correu. Reconheceu os dois réus, apontando Fábio como sendo o segurança e José como sendo o rapaz que estava com a droga.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil RICARDO LACORTE, o qual, em juízo, disse que o local dos fatos é ponto de tráfico. Foram ao local de viatura descaracterizada. O policial Manoel ficou para traz, perto da viatura. Entrou com

Gustavo na viela. Avistaram algo que parecia um movimentação relacionada ao comércio de drogas. Tinham dois provavelmente na campana, que pediram para levantar a blusa. Foi liberado primeiro e se aproximou do rapaz que estava vendendo drogas. Solicitou um porção de droga ao rapaz que estava sentado no sofá com a sacola de drogas na mão. Quando ele foi servir-lo, deu voz de prisão. Na sacola que estava com ele tinha porções de maconha, crack, cocaína e lança perfume, além de dinheiro e contabilidade do tráfico. Seu parceiro Gustavo conseguiu abordar um dos campanas, enquanto o outro conseguiu fugir. Manoel veio para ajudá-los. Informalmente ambos confessaram, mas não disseram quem era o rapaz que fugiu. Negou conhecer os réus. Ao ver os acusados, não conseguiu apontar quem seria o campana e quem seria o rapaz que estava com o entorpecente.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, STJ, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

“Apelações - Tráfico de drogas - Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos - Pedido de absolvição por falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssonos durante toda a persecução penal - Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)” (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

Pois bem, diante da confissão do acusado José, acrescida dos depoimentos seguros e harmônicos dos policiais civis ouvidos na fase policial e em juízo, é de se reconhecer que restou demonstrado, à saciedade, que JOSÉ CARLOS trazia consigo e guardava os entorpecentes apreendidos, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória.

Quanto ao acusado Fabio, a despeito de sua retratação judicial, também não há como deixar de reconhecer que a prova é segura no sentido de que o acusado estava no local auxiliando José na venda do entorpecente, realizando a segurança do local, recepcionando os supostos usuários, os revistando e autorizando a aproximação deles até José.

Note-se que não há qualquer razão para duvidar dos depoimentos dos policiais que

participaram da ocorrência, os quais não conheciam os acusados e, portanto, não teriam motivos para atribuir falsamente ao acusado Fabio a prática de crime tão grave, não tendo as defesas trazido qualquer dado concreto que faça concluir pelo contrário.

Para que fosse aceita a versão judicial do réu, este juízo teria que acreditar que no dia dos fatos houve uma conspiração cósmica que unia a presença do réu no local com a atuação criminosa dos policiais que teriam o acusado injustamente, prestando depoimento falso, e mais, que houve conluio da autoridade policial, que teria lavrado termo de interrogatório falso dos acusados, nos quais teria inserido uma falsa confissão, tese que não pode ser aceita.

É bom ainda ressaltar que se a acusação se baseia nos depoimentos seguros e harmônicos de dois policiais, que não tinham qualquer motivo para acusar injustamente o réu, a defesa se baseia na singela retratação judicial do acusado, desguarnecida de qualquer outro elemento de provas, sendo certo que nem mesmo a supostamente testemunha Marcia que poderia depor confirmando a versão do acusado, caso verdadeira, foi arrolada.

Além da certeza quanto ao envolvimento de ambos os acusados com os entorpecentes apreendidos, também não há dúvidas de que as substâncias destinavam-se ao tráfico, diante da natureza, variedade e quantidade de drogas apreendidas (60,92g de cocaína, distribuídos em porções, 46,14g de crack, distribuídos em porções, 372,68g de maconha, distribuídos em porções, bem como 40ml de substância líquida similar a lança-perfume), da forma como estavam embaladas e separadas, em pequenas porções prontas, das circunstâncias que envolveram as prisões, além de certa quantia em dinheiro, reforçada pela própria confissão do denunciado José, que confirmou que o entorpecente se destinava a venda a terceiros..

Insta consignar ainda que o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, possui tipo multinuclear ou de ação múltipla, visto que a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo é suficiente para a consumação do delito.

Oportuno lembrar que: “o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo” (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006).

Na mesma linha, é o entendimento recente:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA_BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE IGREJA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive trazer consigo, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. (...) 8. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) (Grifei).

E ainda: “considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente.” (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dipp; Quinta Turma; DJ 01/07/2004) (grifei).

Por fim, é notória a situação de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 e a atual crise sanitária enfrentada.

No entanto, a prática do delito em questão não se mostra, a meu ver, mais grave por

estar se dando no contexto de calamidade pública. Até porque admitir a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, sem a devida motivação, pode levar à indesejável exasperação de todas as penas por todos os delitos cometidos durante a pandemia, o que contraria frontalmente a necessidade de individualização e de adequação da pena ao caso concreto.

É por entender que a incidência da agravante exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para prática do delito, ou seja, que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para cometer o crime, o que, a meu ver, não aconteceu no caso concreto, sendo, portanto, de rigor o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, alínea "j", do Código Penal.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal requer nexos entre tal circunstância e a conduta do agente, conforme elenca a jurisprudência a seguir:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 4/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021.

2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20/3/2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial.

3. Agravo regimental não provido" (AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 19/4/2021) (Grifei).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (16,8 G DE COCAÍNA E 35,3 G DE MACONHA). FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE LIMITES LEGAIS MÁXIMOS E MÍNIMOS. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTES E ATENUANTES. ART. 61, II, J, DO CP. CALAMIDADE PÚBLICA. CONTEXTO DE PANDEMIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. 1. Quando a quantidade ou a variedade da droga não é significativa, não há falar em exasperação da pena-base, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade. 2. A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para prática do delito. 3. O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige que o paciente seja primário e de bons antecedentes, condição essa não preenchida pelo paciente. 4. Ordem parcialmente concedida para redimensionar a pena a 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 530 dias-multa, à razão mínima, pelos fundamentos declinados" (HC 654.255/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021) (Grifei).

Desta feita, provada a materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pelas Defesas em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes

a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensinar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

I-) Réu FÁBIO GUIMARÃES DE LIMA:

Na aplicação das penas, levando em conta as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, eis que possui condenação definitiva, transitada em julgado, por fatos anteriores aos apurados nos autos pelo delito de roubo majorado, não apta a gerar reincidência (processo nº 0049714-53.2011.8.26.0224, da 3ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos, cujas penas não foram extintas antes do prazo depurador de cinco anos, ou seja, em 25/02/2014, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 194/197 e F.A. de fls. 37/41 e fls. 185/190). A quantidade e natureza do entorpecente apreendido (60,92g de cocaína, distribuídos em porções, 46,14g de crack, distribuídos em porções, 372,68g de maconha, distribuídos em porções, bem como 40ml de substância líquida similar a lança-perfume) também autorizam o aumento das penas-base, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06. Ademais, o réu praticou novo delito enquanto estava em gozo de livramento condicional, o que torna sua conduta mais reprovável.

Cumprе salientar que aqui é reconhecido o desvalor da conduta social do réu que pratica um crime durante o livramento condicional. Não se está a valorar a condenação propriamente dita, o que será feito na fase seguinte. Nem se diga, portanto, que há violação ao princípio do ne bis in idem. A propósito:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. Ademais, "não há falar em bis in idem com a reincidência valorada na segunda fase, relativa ao crime que cumpria pena em regime aberto, haja vista que a reincidência denota reprovação por haver reiterado prática delitiva após o trânsito em julgado de um crime anterior; por outro lado, o cometimento desse crime durante o regime progredido traiu os fins da pena, em especial a ressocialização, motivo pelo qual é devido incremento da pena dosada" (HC n.408.726/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018).

3. Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp 1072244/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 24/04/2019).

Assim, nesta primeira fase, diante das circunstâncias judiciais apontadas, acresço as penas de 1/4 (um quarto), fixando as penas-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase da pena, ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência, que foi recepcionada pela Constituição Federal por servir como mecanismo de aplicação do princípio da individualização das penas, pois o réu ostenta duas condenações definitivas, transitadas em julgado, em data anterior aos fatos ora apurados, pelo delito de roubo majorado (processo nº 0001354-51.2016.8.26.0535, da 2ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - processo de execução nº 0001450-25.2018.0041, do DEECRIM 1ª RAJ e processo nº 0029777-52.2014.8.26.0224, da 2ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - processo de execução nº 0003022-93.2015.8.26.0502, do DEECRIM 1ª RAJ, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 194/197 e F.A. de fls. 37/41 e fls. 185/190), sendo, portanto, reincidente. Assim, acresço as penas de mais 1/6 (um sexto), fixando-as em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela

qual torno as penas definitivas em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa. Observo que, em face da reincidência específica, fica afastada a causa de diminuição de pena tipificada no artigo 33, §4º da Lei n.º 11.343/06. Não há que se falar em bis in idem mormente porque, para incidência da referida causa de diminuição, faz-se necessário que o réu seja primário, o que não se verifica no caso em análise.

Esse é o forte posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPÇÃO EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA PARA O CRIME DE TRÁFICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE EXACERBADA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVADAS COM BASE NA EXPRESSIVA QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA DE DOIS DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDUTA QUE EXTRAPOLOU À INERENTE AO TIPO PENAL VIOLADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. CONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA E TERCEIRA FASES QUE NÃO ENSEJA BIS IN IDEM. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO DETERMINADO EM FUNÇÃO DO MONTANTE DA REPRIMENDA IMPOSTA. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - A reincidência do paciente constitui óbice suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, haja vista não estar preenchido o requisito legal da primariedade. Precedentes. - Ademais, a orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que o reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes. (...)” (AgRg no HC 630.337/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) (Grifei);

“(...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecida a reincidência do agente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. A utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes. (...) 8. Habeas corpus não conhecido”. (STJ HC 427.620/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 15.03.2018, DJe 20.03.2018 g.n.).

O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo, devidamente atualizado, conforme o prescrito no artigo 38 e seus parágrafos da Lei 6368/76. (O art. 38 da Lei Antitóxicos não foi derogado pela reforma penal de 1984 - TJSP, Tacrim 147.227, Rel. Des. Dante Busana, JTJ, 150/288). Diante da quantidade da pena imposta e reincidência do agente incabível a concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em se tratando de delito equiparado a hediondo, o regime inicial para o cumprimento de pena é o FECHADO, justificável não só ante a latente gravidade do crime, fomentador de tantas outras práticas ilícitas como também pelo fato de os demais regimes não se mostraram adequados para a ressocialização do réu, além do

fato do réu ser reincidente, demonstrando dedicação à prática delitiva, evidenciando que faz do crime um meio de vida e que a medida de reclusão pretérita não surtiu o devido efeito, tanto que praticou novo delito no gozo de livramento condicional.

Deveras, não se mostra adequado, in casu, regime mais brando, afigurando-se oportuno citar, a respeito a seguinte jurisprudência:

“TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. “Ressalto que há determinação expressa no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado”. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP. AP 0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Marco Antonio Marques da Silva. Data do julgamento: 27/06/2013).

Ademais, ainda que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que dizem com a progressão, estranhos a este juízo de conhecimento, são de competência do juízo das execuções criminais, não prosperando a análise, neste momento.

No mais, considerando-se a gravidade do delito cometido pelo réu, o fato do acusado ser reincidente, além de ter permanecido preso durante todo o processo, não poderá o réu recorrer liberdade, afora tratar-se de imposição legal, nos moldes do artigo 44 da Lei nº 11.343/06. O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade do réu subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação. Ainda assim, diante das condições subjetivas e a quantidade de pena aplicada ao acusado faz submergir a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

No sentido exposto, Julio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”.

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: “Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590).

Por fim, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (HC 550.211/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta

Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

II-) Réu JOSE CARLOS SANTOS SILVA:

Na aplicação das penas, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado é primário (certidão estadual de distribuições criminais de fls. 198/199) e praticou o crime nas condições normais previstas no tipo penal, podendo ter a pena-base fixada no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A quantidade de entorpecente apreendido será considerada na terceira fase de aplicação da pena. Na segunda fase, conquanto presente a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir suas penas, eis que já fixadas no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Ausentes circunstâncias agravantes a serem observadas.

Na terceira fase, ausente causa de aumento a ser observada. Presente, por outro lado, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei n.º 11.343/06, uma vez que o acusado é primário e não há notícia de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. O fato de trazer considerável quantidade de entorpecente não permite um juízo de certeza de que integre organização criminosa de modo a afastar a aplicação da minorante, tratando-se de mera suposição. Não é possível, contudo, a aplicação do redutor em seu grau máximo. Isto porque o réu foi surpreendido com considerável quantidade de entorpecentes (60,92g de cocaína, distribuídos em porções, 46,14g de crack, distribuídos em porções, 372,68g de maconha, distribuídos em porções, bem como 40ml de substância líquida similar a lança-perfume), além das drogas serem variadas, sendo parte delas de elevada nocividade e alto poder viciante (cocaína). Diante das circunstâncias do caso, reduzo das penas em 1/2 (metade), fixando-as, em definitivo, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias- multa.

O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo, devidamente atualizado, conforme o prescrito no artigo 38 e seus parágrafos da Lei 6368/76. (O art. 38 da Lei Antitóxicos não foi derogado pela reforma penal de 1984 - TJSP, Tacrim 147.227, Rel. Des. Dante Busana, JTJ, 150/288).

Ressalto que a Lei n.º 11.343/06, a despeito de ter trazido causa de diminuição de pena (artigo 33, § 4º), que permite a fixação de pena privativa de liberdade em patamar mínimo de um ano e oito meses, inferior, portanto, às penas do delito de furto qualificado ou de venda de mídias piratas, por exemplo, que configuram condutas mesmo grave, vedou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A meu ver, respeitado entendimento contrário, não entendo que tal dispositivo seja inconstitucional, pois reflete a vontade do legislador de, embora permitir a aplicação de uma pena branda, inferior às previstas para delitos tidos por menos graves, quis que seu cumprimento fosse realizado em regime inicial fechado sem possibilidade de fixação de penas alternativas, entendimento adequado para desestimular a reiteração delitiva.

Nada obstante, diante da recente decisão proferida no habeas corpus nº 596.603 - Sp (2020/-170612-1) do E. STJ, em cumprimento a ordem coletiva concedida, fixo regime inicial semiaberto, o qual reputo ser o mais adequado, a despeito da pena fixada, considerando que o réu embora tecnicamente primário, já teve passagem na Vara da Infância e Juventude e pouco tempo depois de ser agraciado com liberdade provisória nesses autos, voltou a delinquir, estando atualmente preso sob a acusação de ter praticado delito de roubo. Ademais, as circunstâncias do caso concreto, notadamente a posse de considerável quantidade de entorpecente, de natureza variada (maconha, cocaína, crack e lança perfume), sendo parte delas de elevada nocividade e alto poder viciante (cocaína/crak), ainda mais reforçam a adequação do regime semiaberto.

Anda obstante, considerando a quantidade da pena aplicada e a primariedade do réu, em cumprimento a ordem concedida no Habeas Corpus nº 596.603 - SP (2020/-170612-1)

do E. STJ, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, em localidade a ser definida em sede de execução, pelo período da pena privativa de liberdade imposta, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal (10 dias-multa), pelas mesmas razões quando da fixação da pena-base.

O réu poderá apelar em liberdade levando o fato de responder solto este processo, bem como de ter sido aplicadas penas alternativas.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de:

I - CONDENAR FÁBIO GUIMARÃES DE LIMA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, caput, da Lei Federal nº. 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso I, do Código Penal, afastada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública pelo Decreto nº 06, de 20 de março de 2020), ao cumprimento de 7 (SETE) ANOS, 3 (TRÊS) MESES e 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 729 (SETECENTOS E VINTE E NOVE) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

II - CONDENAR JOSE CARLOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, caput e §4º, da Lei n.º 11.343/06, do Código Penal, afastada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública pelo Decreto nº 06, de 20 de março de 2020), ao cumprimento de 2 (DOIS) ANOS e 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO, substituídos por prestação de serviços à comunidade, em localidade a ser definida em sede de execução, pelo período da pena privativa de liberdade imposta, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal (10 dias-multa), além do pagamento de 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

O réu FÁBIO não poderá apelar em liberdade. Recomende-se o réu no local onde estiver preso.

O réu JOSÉ poderá apelar em liberdade.

Considerando a relação do dinheiro apreendido nos autos (R\$ 35,00 - B.O. de fl. 11) com o tráfico ilícito de entorpecentes, determino o seu perdimento em favor da União, autorizando a transferência dos valores para a conta bancária especial mantida pela Secretaria Nacional Sobre Drogas. Com o trânsito em julgado da sentença, oficie-se à autoridade policial a fim de que providencie a sua transferência, imediatamente.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais. Defiro aos acusados os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Insta consignar que a cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que os acusados têm condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, § 3º, do C.P.C.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação dos réus, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação dos réus.

P.I.C.

Guarulhos, 10 de março de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA